



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/412/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

תובעים	1	אשר זאדה דיין (נמחק)
	2	גד מקס אלביליה
ע"י ב"כ: עו"ד יניב דבוש ו/או חגית רקובסקי-שביט מרח' אחד העם 25 רחובות 7624702 טל': 08-6373654, פקס: 153-8-6373654		
	נגד	
נתבעים	1	שמעוני יעקב
	2	שמעוני רבקה
	3	צדוק סלח סיגל טפחה סלח
ע"י עו"ד יעקב שדה מרח' אבן גבירול 133 תל אביב 6203706 טל' 03-5448244		

פסק דין

1. לפניי תביעה לסילוק יד בגין בנייה שבשטח הגגות הקרובים לדירות הנתבעים וכן בגין שלשלאות שהוצבו על ידי הנתבעים, כנטען, שחוסמות את הגישה לאזור בלוני הגז.
2. התביעה הוגשה בשנת 2018 ונדונה בפני המפקחת קציר-ברין, ומשנבצר מהמפקחת קציר-ברין להמשיך לדון בתביעה מצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**), להמשיך ולדון בתביעה למן הנקודה אליה היא הגיעה. הצדדים ניסו להגיע להסכמות והבנות, ועל כן התיק הושהה לתקופה ומשעה שהצדדים לא השכילו להגיע לעמק השווה הגיעה העת להכריע בתביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/412/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית העובדות וטענות הצדדים

3. ענייננו בבית משותף ברחוב קרייתי 13, חולון הידוע גם כגוש 7161 חלקה 97 (להלן: **הבית המשותף**) בן שתי קומות (על עמודים) ובו 4 דירות סה"כ, שתיים בקומה הראשונה ושתיים נוספות בקומה השנייה, בצמוד לשטח הגגות. הבית ראוי להירשם כבית משותף אך טרם נרשם ככזה וממילא אין לו תקנון מוסכם ולא תשריט בית משותף.
4. התובעים הם בעלי דירות בקומה הראשונה בבית המשותף כבר משנות השמונים של המאה שעברה, והנתבעים הם הבעלים של שתי דירות בקומה העליונה בבית המשותף (נכון ליום הגשת התביעה); נתבעים 1-2 (להלן: **שמעוני**) הם בעלי הדירה משנת 1986 והנתבעים 3-4 (להלן: **סלח**) רכשו בשנת 2006 או בסמוך לכך את דירתם ממשפחת הררי (להלן: **הררי**). יצוין כבר כעת כי זה לא מכבר שמעוני מכרו את דירתם לצד ג' והם אינם מתגוררים עוד בדירה, אך התובעים עמדו על תביעתם נגד שמעוני.
5. לטענת התובעים, הנתבעים בנו ללא היתר כדין וללא הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף על גבי הגגות בהיקף של 58 מ"ר לכל דירה, וזאת על אף שחלק מהשטח עליו נבנו המבנים הלא חוקיים מהווה רכוש משותף. התובעים טוענים כי כנגד שמעוני הוגשו בעבר כתבי אישום והם אף הורשעו ביום 7.9.1999 בעבירה של בנייה שלא כדין וללא היתר ולאחר שלא קיימו צו הריסה שניתן כנגדם הוגש נגדם כתב אישום נוסף ביום 7.12.2011. כמו כן נגד הררי הוגש כתב אישום דומה ביום 21.12.1998 בגין בנייה בלתי חוקית, אך הררי לא הרסו את הבנייה וסלח נכנסו בנעליהם ואף הגדילו ובנו מעבר לשטח שנבנה על ידי הררי.
6. נטען, כי באמצעות הבנייה הנתבעים משתלטים על חלקים מהרכוש המשותף שגם לתובעים זכויות בו תוך ניצול זכויות בנייה השייכות לכלל בעלי הדירות בבית המשותף. כמו כן נטען כי בשל הבנייה הבלתי חוקית לא ניתן לרשום את הבית כדין ובכך גם כן נפגעות זכויותיהם של התובעים. הובהר, כי התובעים אינם מסכימים ואף הביעו התנגדות לבניית הנתבעים על הרכוש המשותף וניצול זכויות הבנייה המשותפות, מרגע שגילו על התחלת הבנייה לפני שנים רבות פנו לעירייה בתלונה שהובילה להליכים פליליים נגד הנתבעים. ואולם, צו ההריסה עומד על תילו משנת 1999 ללא אכיפה.
7. עוד צוין בכתב התביעה כי הנתבעים מוסיפים חטא על פשע, וגם את שטח בלוני הגז עשו הנתבעים רכוש לעצמם, כאשר התקינו מנעול וגדר על השטח המשותף בו נמצאים בלוני הגז של כלל דיירי הבית המשותף, וכאשר מי מבעלי הדירות מעוניין לבצע החלפה של בלון גז עליו לבקש רשות מהנתבעים.
8. במסגרת כתב הגנתם טענו הנתבעים כי טענות התובעים התיישנו זה מכבר והועלו בשיהוי ניכר, לאחר עשרות שנים שהם מודעים ואף הסכימו למצב הקיים. לכן, לא בכדי התובעים לא טרחו לפרט את המועדים הרלוונטיים בכתב תביעתם כגון מועד רכישות הדירות, סיום הבנייה וכיו"ב. כמו כן נטען שהתביעה לוקה בחוסר תום לב וניקיון כפיים, תוך הסתרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/412/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרטים עובדתיים מהותיים, שאף עולה לכדי הטעיה במכוון לשנות את המוסכם. נטען, שהתובעים הסתירו את העובדה שהנתבעים הם בעלי הזכויות הבלעדיים בגג הבית המשותף לרבות בזכויות הבנייה אשר הוסכם בין בעלי הדירות שיוצמדו לדירתם ומכוח הסכמות אלה הנתבעים בנו תוספות בנייה על גבי הגגות. נטען כי שמעוני בנו בתום לב ובהסכמת בעלי הדירות על גג דירתם סככה מפלסטיק יחד עם הררי, ולצורך כך שינו את מיקומם של הדוודים והעלו אותם לגג הבניין, בידיעת והסכמת התובעים. אמנם בשנת 1998 הוגש כתב אישום כנגד שמעוני בשל בניית אותה סככה, אך פירוק הסככה לא נעשה חרף התחייבותם לעשות כן וזאת לטענתם בשל גילם המבוגר ומצבם הרפואי. בשנת 2011 הוגש כתב אישום נוסף כנגדם ואז בנם של הנתבעים שמעוני פירק את הסככה. באשר לסלח נטען, כתב אישום שהוגש נגד הררי בגין הסככה בוטל בהסכמה ומאז שסלח רכשו את הדירה בשנת 2006 לא נשמעה כלפיהם כל השגה כלפי הבנייה שנעשתה על הגג.

9. הנתבעים גם מפנים להסכם מיום 29.10.2006 שצורף כנספח 2 לתצהיר סלח, שלטענת הנתבעים נוסח בשעתו על ידי עו"ד רוטברט (להלן: **רוטברט**). במסגרת ההסכם הוסכם, כנטען, על חלוקת הרכוש המשותף וזכויות הבנייה כלהלן: שהרכוש המשותף הנוגע לגג הבית המשותף זכויות הבנייה הנלווים לו יהיו שייכים לנתבעים בלבד ויוצמדו לדירותיהם, ובתמורה לכך יוצמדו לדירות התובעים שטחי הגינות בחצר הבניין (להלן: **הסכם 2006**). עוד צוין כי במשך השנים עו"ד רוטברט החל ברישום הבניין כבית משותף במטרה לרשום את הדירות וההצמדות הנלוות להן אולם טרם השלים את הרישום נכון למועד זה.

10. עוד טוענים הנתבעים כי אין לתובעים כל מניעה לגשת לדוודים המצויים על גג הבניין ככל שחפצים בכך. באשר לבלוני הגז, המנעול אשר נועל את כלוב המתכת שבתוכו ממוקמים בלוני גז הותקן על ידי חברת הגז למנוע את גניבתם, כאשר כל הדיירים קיבלו מפתח למנעול מהתובע.

11. בכתב התשובה לכתב ההגנה, הכחישו התובעים את הנטען כי הסכימו למצב הקיים לאורך השנים ולראיה שהתובעים התלונו שוב ושוב בפני הנתבעים, העירייה ועו"ד רוטברג אודות ההשתלטות של הנתבעים על הגג. התובעים גם מכחישים כל הסכמה שניתנה בכתב או בעל פה. באשר להסכם 2006 נטען כי הסכם זה נערך לצורך הסכם שכר טרחה וטיוטה לרישום הבניין כבית משותף ומאז שנחתם לא נעשה דבר על מנת לקדם את הנושא של רישום הבניין כבית משותף. נטען כי ההסכמה לחלוקה הייתה בתנאי שהבית יירשם כבית משותף, אך הדבר לא קרה עד עצם היום הזה וממילא אין כל תוקף לחלוקה. בנוסף, התובעים מציינים כי הסכם זה נעשה בכתב יד על גבי דף נייר חלק ובמהלך ישיבת דיירים שגרתית. ההסכם נשאר בידי סלח ועותק ממנו לא ניתן לתובעים מעולם. כמו כן, הנתבעים אינם מכירים בחלקו הראשון של ההסכם לפיו שטח הגינות יהיה לבעלי הדירות בקומת הקרקע, וכך למעשה הנתבעים מרוויחים גם את שטח הגגות וגם את שטחי הקרקע לרבות החניות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/412/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים גם מכחישים כי העתקת מקום הדוודים הייתה בידיעתם והסכמתם ונטען שלמעשה אין היום גישה לדוודים. כמו כן, התובעים מכחישים כי חברת הגז היא זו שנעלה את כלובי הגז, וממילא לא קיבלו לידם מפתח, חרף טענות התובעים.

ההליכים הדיוניים

12. ביום 29.4.2019 התקיים דיון בפני כב' המפקחת דגנית-קציר ברין, בנוכחות הצדדים אך התובע 1 לא התייצב לדיון. במהלך הדיון התובעים הציגו תשריט של הבית המשותף, שתוקפו לא הוברר עד תום וניתנה לנתבעים שהות לטעון ביחס למהימנותו של המסמך. כמו כן, במסגרת הדיון ניתן תוקף של החלטה להתחייבות הנתבעים לאפשר לתובעים הנחת דוד שמש על הגג או תיקונו ככל שהדבר יידרש לרבות דרך דירתם ובכפוף לתאום מראש איתם. לסופו של הדיון התיק נקבע להוכחות וכן נקבע מועד לביקור במקום.

13. ביום 13.5.2019 הגישו הנתבעים הודעת עדכון ממנה עולה כי לאחר עיון ובחינת התשריטים שהוצגו על ידי התובעים במהלך הדיון, למיטב ידיעתם התשריטים אינם משקפים את מצבו הנוכחי של הבניין אלא את מצבו הראשוני במועד בנייתו לפני עשרות שנים. בהחלטת המפקחת מיום 14.5.2019 נקבע כי על הנתבעים לפרט את הסתייגויותיהם מהתשריט שהוצג ככל שהם סבורים כי אינו מהווה תמונה נאמנה של מושא הבית. ביום 2.9.2019 התקיים ביקור במקום, שלמיטב הבנתי לסופו הוחלט על ידי המפקחת קציר-ברין שמפתח כלוב הגז יועבר לכל בעלי הדירות, וכן ניתנה לצדדים שהות לניהול הידברות ביניהם על סמך הצעות המפקחת.

14. ביום 21.1.2021 הגישו הנתבעים בקשה לעיכוב הליכים, נוכח המרצת פתיחה שהגישו הנתבעים לבית המשפט המחוזי לקבלת פסק דין שיכיר בזכויותיהם הקנייניות בגג. במסגרת הבקשה צוין כי לאור היחשפותם של הנתבעים למסמכים שהיו אצל עו"ד רוטברט התגלה הסכם משנת 2009 שסיכם את חלוקת הבעלות ברכוש המשותף ואחוזי הבנייה (להלן: הסכם 2009), ומשכך ביקשו הנתבעים למצות את זכויותיהם על דרך של הגשת תביעה לבית המשפט המחוזי. למען שלמות התמונה יצוין כי בסופו של יום קיבלו הנתבעים את הצעת בית המשפט ומשכו את תביעתם זו (פסק דין מיום 19.7.2021 בת"א 73857-12-20 שמעוני נ' זאדה).

15. נוכח התנגדות התובעים לבקשה לעיכוב הליכים, הורתה המפקחת קציר-ברין על דיון נוסף בתיק ומאחר שנבצר מהמפקחת קציר-ברין להמשיך ולטפל בתיק, הדיון הנוסף ביום 14.6.2021 התקיים בפניי, במהלכו ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות ואף קבעתי ביקור במקום אך גם ניסיון זה לא צלח, וביום 29.7.2021 ביקשו התובעים להמשיך בניהול התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/412/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. ביום 4.10.2021 התקיים דיון נוסף בפניי שגם במהלכו ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות על סמך הבנות קודמות, אך לצער הלב, למרות שהצדדים ניסו לאורך חודשים רבים להגיע להסדר, הוא לא הבשיל לכדי הסכם והתיק נקבע להוכחות ליום 22.5.2023. ביני לביני, התקבלו עדכונים לתיק לפיהם התובע 1 הלך לעולמו והנתבעים שמעוני מכרו את דירתם לצד שלישי. עוד יצוין, שעובר לדיון ההוכחות הנתבעים הגישו הודעות ובקשות רבות הנוגעות, בין היתר, לעיכוב הגשת התצהירים על ידי התובעים, מעמד התובעים בשל פטירתו של התובע 1 וכן בעניין הרחבת חזית בתצהירי התובעים. לענייננו אומר, כי במסגרת דיון ההוכחות ביום 8.6.2023 קיבלתי חלק מטענות הנתבעים והוריתי על מחיקת חלקים מתצהירי התובעים. כמו כן לאחר מספר החלטות בנושא, התובעים הואילו למחוק את נתבע 1 מכתב התביעה תוך שמירה על טענות (הודעת התובעים מיום 18.07.2023).

17. ביום 8.6.2023 התקיים דיון הוכחות במהלכו נחקרו התובע 2, הנתבעים וכן בנם של שמעוני. מר דניאל דיון, בנו של התובע 1 שהגיש גם כן תצהיר לא חש בטוב במהלך הדיון ועל כן עדותו נדחתה, אך משעה שהתובעים מחקו את התובע מכתב התביעה נמחק גם תצהירו (ראו החלטתי מיום 31.8.2023).

הצדדים סיכמו טיעוניהם בעל פה בדיון שנערך ביום 31.8.2023 והגיעה העת להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

18. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר העיון בכל הנוגע לסעד-הסרת הבנייה מהגגות, מצאתי לקבל את התביעה במלואה נגד הנתבעים סלח ולדחות את התביעה נגד הנתבעים שמעוני שכבר אינם בעלי דירה בבית המשותף. בנוסף, מצאתי לדחות את התביעה בכל הנוגע לשלשלאות שהונחו בכלובי הגז, והכל כפי שיבואר להלן.

19. סביבתנו הנורמטיבית בהתאם לכתב התביעה, בסעיף 71ב לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", כלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפא או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה... ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/412/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הרחבה" הוגדרה בסימן זה בחוק כלהלן:

"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר
בניה לפי תכנית בת-תוקף"

אומר בקצרה, כי סעיף 71ב הוא חלק מסימן ג1 לחוק המקרקעין שהתווסף כחלק מתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין אשר החליף את ההסדר החוקי שנהג לפני התיקון לפיו על מנת לאשר הרחבה של דירה על חשבון הרכוש המשותף היה צריך לקבל הסכמה של כלל בעלי הדירות בבית המשותף. תיקון 18 לחוק המקרקעין קבע אפוא רוב מופחת לצורך הרחבת דירה תוך יצירת תנאים ואיזונים שישמרו על זכויות הכלל (ראו דברי הסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף), התשנ"ה-1994 ה"ח 114 (7.11.1994); רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא, בפסקאות 10-11 (2.8.2012) **דוד עטייה נ' ליאור שגיא**, בפסקאות 10-11 (2.8.2012)).

20. הנה כי כן, מלשון הסעיף עולה שההסכמה להרחבת דירה צריכה לכלול שלושה מרכיבים: האחד, הסכמה להוצאה של חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה; השני, הסכמה לבנייה שמטרתה הרחבת דירה והשלישי – הסכמה לחלוקה של זכויות הבנייה הנדרשות לצורך הרחבת הדירה. הסכמה זו צריכה להיות מפורשת וברורה לעניין שלושת הרכיבים שצוינו לעיל, כאשר נטל ההוכחה רובץ לפתחו של בעל הדירה המבקש להרחיב דירתו להראות כי בידו הסכמה כנדרש (ע"א 45/15 **נבולסי נ' נבולסי**, בפסקה 12 (15.5.2017); עע"מ 795/19 טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב, פסקה 2 (15.7.2020) **טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב**, פסקה 2 (15.7.2020); רע"א 259/99 **חברת פליצה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)).

21. תנאי נוסף ומצטבר לתנאים הנ"ל להרחבה כאמור בהתאם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין הוא כי בידו של המבקש להרחיב דירה היתר בנייה כדין או "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף", כאמור בהגדרת המונח "הרחבה" כמובא לעיל.

22. בענייננו, אין מחלוקת כי קיימת התחייבות חוזית שחלק משטח הגגות יוצמדו לדירות הנתבעים. ואולם, אין בכך כדי לפטור את בעלי הדירות המבקשים לבנות על שטח הגגות מלקבל הסכמת בעלי דירות בבית המשותף, הן לעניין הבנייה והן לעניין חלוקת זכויות הבנייה (ראו: מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 245/19 גרין חיים דב נ' שטרנבוך איטה לאה, בפסקה 24-26 והאסמכתאות שם (4.3.202) **גרין חיים דב נ' שטרנבוך איטה לאה**, בפסקה 24-26 והאסמכתאות שם (4.3.202)). זאת במיוחד, כאשר "ברגיל, הצמדה של שטח לדירה מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד אך אינה מקנה לו זכות לבנות על השטח המוצמד, וניצול זכויות הבנייה בבית המשותף מותנה אפוא בהסכמת יתר בעלי הדירות" (רע"א 11017/08 **פל נ' ליבוביץ**, בפסקה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/412/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14 (16.8.2010) (להלן: **עניין פל**); וראו: ע"א 7808/21 **אחוזת חלקה 180/8 בגוש 6940 בע"מ** ו-16 **אח' נ' חברת גג בית הדר בע"מ**, בפסקה 23 (11.7.2023)). מנגד, נקבע בפסיקה, שגם כאשר עסקינן בבנייה על רכוש משותף שהוצמד, חלות הוראות סעיף 71 לחוק על כל תנאיו לרבות בעניין הרוב הדרוש לצורך בנייה כאמור (**עניין פל**, בפסקה 15).

23. מכל מקום, העולה מן האמור שעל בעל דירה המבקש לבנות גם בשטח המוצמד לעמוד בכלל התנאים שבסעיף 71 לחוק, קרי – גם לקבל הסכמה מפורשת של בעלי הדירות הן לעניין הבנייה עצמה והן לעניין היקף זכויות הבנייה הדרושות להרחבת הדירה ושניתן לקבל בעניינה של הבנייה היתר בנייה כדין.

המיושם לענייננו

טענות סף

24. טרם אדרש לטענות התביעה, יש לסלק את טענת הנתבעים להתיישנות התביעה. הנתבעים הסתמכו על הוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 שעניינה "תקופת התיישנות מוסכמת" שאינה ממין העניין. מנגד, בענייננו חלה הוראת סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין הקובעת כי חוק ההתיישנות לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים. מעבר לכך, מאחר שעסקינן בתביעה שעילתה הסגת גבול במקרקעין, הרי שמדובר בעוולה מתמשכת שעילתה מתחדשת מיום ליום וממילא אינה מתיישנת (ע"א 3137/15 **עיריית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית**, פסקה 11 (21.5.2018); ע"א 1206/16 **חברת יהלומי סמואל-רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה**, פסקה 38 (9.10.2018); ע"א 1551/19 **פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גובר**, פסקה 12 (15.1.2020)). משכך, דין טענת ההתיישנות להידחות.

25. עוד נטען שהנתבעים מושתקים מלתבוע את הנתבעים בגין הבנייה בשל השיהוי הרב בהגשת התביעה ושתיקת הנתבעים לאורך השנים שמהווה רשות בלתי הדירה לבנייה (ראו עמ' 5 שורות 17-21 לסיכומי התובעים). באשר לטענת השיהוי, הרי ש"היא טענה קשה ברבדים שונים" ומשוכת ההוכחה – המוטלת על כתפי הנתבעים – היא גבוהה (ע"א 6805/99 **תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים**, פ"ד נז(5) 433, 445-448 (2003)). לענייננו, אינני סבור שהנתבעים השתתו על זכויותיהם עד כדי שזנחו את זכות התביעה. במקרה דנא, הבנייה הלא חוקית בצורתה זו או אחרת היא במקומה מקדמת דנא, ולאורך כל הדרך נעשו ניסיונות שונים על מנת להסירה, בתחילה בפן האכיפתי מכוח דיני התכנון והבנייה והראיה שנגד הנתבעים או קודמיהם הוגשו כתבי אישום (ולא נעלם מעיני שהצדדים חלוקים בשאלה האם הנתבעים הם אלה שהגישו תלונה נגד הנתבעים), דרך ניסיונות להגיע להבנות בנושא כפי שניתן להיווכח מהסכמי 2006 ו-2009 וכלה בתביעה זו שהוגשה בשנת 2018. על טיבן של ניסיונות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/412/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אלה אעמוד בהמשך, אך מכל מקום לא ניתן לקבוע שהתובעים השתהו על זכויותיהם עד כדי שינוי מצבם של הנתבעים לרעה. מה עוד שמדובר בזכות בעלת משקל רב כתביעה למימוש זכות במקרקעין במסגרתה ייעשה שימוש מצומצם בטענת השיהוי על מנת לחסום תובע מבירור תביעתו (ע"א 9839/17 **הביטאט בע"מ נ' CAFOM**, פסקאות 32-35 (17.12.2018)).

התביעה נגד שמעוני

26. אין מחלוקת ששמעוני כבר אינם בעלי דירה בבית המשותף (סעיף 9 לתצהיר התובע 2). אף על פי כן, התובעים עמדו על התביעה נגד שמעוני בטענה שפסק הדין יחייב גם את רוכשי הדירה של שמעוני שבאו בנעליהם (ראו עמ' 2 לפרוטוקול מיום 8.6.2023). דא עקא, שהתובעים לא טרחו לבקש לתקן את כתב התביעה ולהגיש תביעה נגד רוכשי דירת שמעוני על אף שהם בעלי הדירה הנוכחית והם הזכאים כיום להתדיין בפניי, ואין נפקות כיום למתן סעד אופרטיבי נגד שמעוני.

27. יתר על כן, והוא העיקר: על פי האמור בתצהיר התובע 2, הרוכש של דירת שמעוני הרס את כל הבנייה הקיימת של שמעוני (קרי, הבנייה מושא התביעה), ולדבריו ביצע בנייה חדשה על שטח הגג (סעיף 12 לתצהיר). בנסיבות אלה אני סבור, שגם אם בידי הסמכות לדון בעניינם של שמעוני על אף שאינם בעלי דירה (ראו סעיף 73 לחוק המקרקעין והשוו לע"א 402/80 **"אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ**, פ"ד לה(3) 309 (1981)), הרי שבהינתן הודאת בעל דין לפיה הבנייה מושא התביעה נהרסה, הרי שממילא הסעד התייטר. כמו כן, התשתית העובדתית שהונחה בפניי אינה תואמת למצב העובדתי היום ובעלי הדין הרלוונטיים לסעד המבוקש לא צורפו להליך. על כן אין בפניי התשתית העובדתית הרלוונטית למתן סעד בעניינה של דירת שמעוני.

28. אשר על כן, דין התביעה נגד שמעוני להימחק. כמובן שאין באמור כדי למנוע מהתובעים להגיש תביעה באותו נדון נגד הבעלים החדשים של הדירה ככל שקיימת בשטחם בנייה בלתי חוקית.

התביעה נגד סלח

29. כאמור, הנחת המוצא לענייני כי הנתבעים בנו בשטח הגג הקרוב לדירתם, כאשר גם התובעים מודים שחלק מהבנה על השטח מוצמד תוך ניצול זכויות בנייה החלות על המקרקעין, ואילו "חלק נכבד מתוספת הבנייה" הן על שטח הרכוש המשותף (סעיף 11 לכתב התביעה). כפי שצוין לעיל, אין למעשה נפקא מינה האם הבנייה היא ברכוש המשותף או בשטח המוצמד לדירת סלח, מאחר שבשני המקרים על סלח להראות כי התמלאו התנאים שבסעיף 71 לחוק המקרקעין לבנייה האמורה. משכך, גם איני רואה צורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/412/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להכריע בשאלת תיחוס הבנייה, ברכוש המשותף או בגג המוצמד, על אף שהצדדים הרחיבו טיעוניהם בכך (ראו חקירתו הנגדית של התובע 2 בעמ' 5-6 לפרוטוקול).

30. מכאן אפנה להנחת המוצא השנייה, והיא שלבנייה בגגות הקרובים לדירת סלח אין היתר בנייה כדין. עיינתי בתצהיר סלח ובתיק מוצגיו ולא מצאתי בו זכר להיתר כאמור. יתר על כן, גם לא מצאתי חוות דעת או אישור מוסמך לכך שניתן יהיה לקבל היתר לבנייה האמורה וזאת על אף שבנסיבות על סלח מוטל הנטל להוכיח קיומו של היתר בנייה או אפשרות לקבל היתר כזה (ראו: רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן, בפסק דינו של כבוד השופט י' עמית (23.2.2012)).

31. יתר על כן, הנתבעים סלח אינם מכחישים כי נגד הררי מהם רכשו את הדירה הוגש בשעתו כתב אישום, בשנת 1998, שלטענתם בוטל בהסכמה (סעיף 35 לתצהיר סלח) ואף על פי כן, בהסכם רכישת הדירה משנת 2006 (סומן ת/י), נכתב במפורש כי הובא לידיעת הרוכש (סלח) שהמוכר (הררי) בנה על גג הדירה ללא היתר ושהוצא נגד הבנייה צו הריסה שמעולם לא מומש (סעיפים 8.1.3-8.1.1 להסכם). לשלמות התמונה יצוין כי סלח לא טען מעולם שהרס את הבנייה האמורה, ובעדותו התחמק מהשאלה האם ניתן היתר כדין לבנייה (עמ' 17 שורות 16-32):

ש": יש לך היום בניה בלתי חוקית בדירה
ת: לא

ש: קיבלת היתרים על הבניה שלך?

ת: כשקונים בית אם יש אותו בעיה יש הערת אזהרה בטאבו. כשאני קניתי לא היה כל הערת אזהרה בטאבו. אם הייתה בעיה לא היו מעבירים את הטאבו אליי.

ש: אבל אתה אומר שלא הוצאת היתרי בניה נכון

ת: אני לא צריך להוציא. אני קניתי לפי מסמך שאומר חוק התיישנות. חוק התיישנות בשבילי זה שאי אפשר להוציא את המת מהקבר ולשפוט אותו

ש: מצד אחד ענית שאין לך חריגות בניה

ת: אין לי אבל עכשיו ענית למה אתה צריך היתרי בניה

ת: אני קניתי את זה as-is

ש: אתה מודע לזה שאין לך היתרי בניה

ת: אני מודע לזה שיש חוק התיישנות על הבניה.

ש: אם אתה טוען שאין לך חריגות בניה למה אתה טוען ומסתמך על טענת התיישנות בנוגע לבניה שקיימת לך, או שאין לך חריגות בניה, או שיש לך ואתה טוען טענת התיישנות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/412/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ת: אתה טוען שיש לי חריגות בניה ואני אומר לך שלא".

מעדותו אף נמצאתי למד שהוא מודע לכך שבכל עת ניתן יהיה להסיר את הבנייה הבלתי חוקית, על אף שכתב האישום נגד הררי בוטל (ראו עמ' 15 שורה 31 לפרוטוקול). רוצה לומר, שלא זו בלבד שסלח לא דאגו להריסת המבנה הלא חוקי, הם גם לא דאגו להוצאת היתר למבנה וממילא מדובר בבנייה לא חוקית ושלא הוכח כי ניתן יהיה לקבל היתר בנייה. 32. בכך יכולנו לעצור הילוכנו ולקבוע כי מדובר בבנייה שלא כדין מאחר שאינה עומדת באחד התנאים האמורים בסעיף 71ב שהוא קבלת היתר כדין, וזאת גם אם נניח שניתנה הסכמה של יתר בעלי הדירות לבנייה האמורה. ואולם, הצדדים טענו ארוכות בעניין הסכמי 2006 ו-2009 וראיתי לנכון להתייחס גם לטענות אלה.

האם הסכמים 2006 ו-2009 מהווים הסכמה לבנייה?

33. ככל שירדתי לסוף טיעונם של הנתבעים, הם מטילים את מלוא כובד טיעוניהם על הסכם 2006 שלטענתם השתכלל לכדי הסכם מחייב בחתימת בעלי הדירות. אציין, שהסכם זה אוחד עמוד וחצי, בכתב יד משורבט וחתום על כלל בעלי הדירות מלבד אשר דיין שבנו, דניאל דיין חתום במקומו. הנתבעים תומכים יתדותיהם בסעיף האחרון להסכם שלשיתם מקבע את הסכמת בעלי הדירות לבנייה על הגגות כלהלן:

"הדיירים מסכימים כי עת יירשם הבית המשותף יוצמדו הגינות לבעלי הדירות בקומת הקרקע ואילו הגגות/אחוזי הבניה יהיו לבעלי הדירות בקומה העליונה (השנייה)"

הנתבעים גם מסתמכים על הסכם 2009 שלטענתם אשרר את ההסכם משנת 2006 (עמ' 4 שורות 16-17 לסיכומי הנתבעים) וגם הוא קובע בלשון דומה כי בעת רישום הבית המשותף תיעשה חלוקה כאמור לעיל בהסכם 2006. אלא, שבהסכם 2009 – עליו חתומים כלל בעלי הדירות מלבד התובע 2, נכתב תיאור ארוך ומפורט של ההצמדות העתידיות. ואולם, גם בהסכם זה, כאשר בסעיף 3 להסכם נכתב במפורש כי ההצמדות תבוצענה "עת יירשם הבית המשותף".

34. אומר בקצרה, שהתובעים לא ידעו להסביר מדוע היה צריך לאשרר את הסכם 2006 אם לדבריהם הסכם זה היה שריר וקיים בשעתו. סלח בעדותו טען כי הסכם 2006 (שלא היה לו צד) היה הסכם מחייב ומאחר שהוא נכתב בכתב יד "היה צריך לעלות [אותו] בדפוס בצורה מסודרת" (עמ' 16 שורה 41 לפרוטוקול). ואולם, הסבר זה דחוק ומוקשה נוכח פער הזמנים והפירוט הרב שבהסכם 2009 ביחס להסכם 2006. גם יוסי אשכנזי, בנם של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/412/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים אשכנזי אשר לדבריו ליווה את הוריו בכל שלבי רכישת הדירה וההתנהלות עימה לאחר מכן, לא ידע לומר האם אשכנזי ראו בהסכם 2006 או בהסכם 2009 כהסכמים שרירים ותקפים (שם, בעמ' 12, שורות 4-10). כאמור, הנתבעים שמו יתבססו על הסכם 2006 כי הסכם זה נחתם גם על ידי תובע 2 שלא הסכים לחתום על הסכם 2009, ונטען כי בהיעדר הודעת ביטול הרי שמדובר בהסכם שריר וקיים (עמ' 4 לסיכומים שורות 18-19). איני סבור שיש ממש בטענה זו ולו מן הטעם שבהתנהגות הצדדים ובכלל זה עצם עריכת הסכם 2009 הוכח שהצדדים לא ראו עצמם מחויבים בהסכם. במילים אחרות, וכפי שיבואר להלן, בהסכם 2006 לא התקיימו רכיבי המסוימות וגמירות הדעת. כאמור, הסכם 2006 אינו מפרט את חלקי ההצמדות בעת רישום הבית המשותף ולכך מתייחס ביתר פירוט הסכם 2009, שהנתבעים לא ידעו, כאמור, להסביר את סיבת עריכתו. וזאת ידוע כי "יסוד המסוימות אינו מנותק מיסוד גמירות-הדעת. קיימים קשרי גומלין בין שני יסודות אלה השלובים זה בזה, ומאפשרים ללמוד על דבר קיומו של האחד, מתוך בחינתו של האחר. כך, קיומה של מסוימות יש בה כדי להעיד, בדרך-כלל, על גמירות-הדעת של הצדדים להתקשר בהסכם" (ע"א 3380/97 **תמגר חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' בלהה גושן** פ"ד (4) 673, 683 (1998)). מכאן גם, כי היעדרה של מסוימות עשויה להעיד על היעדר גמירות-דעת שנלמדת בין היתר מ"נסיבות העניין, התנהגות הצדדים ואמירותיהם לפני ואחרי כתיבת המסמך וכן את תוכן המסמך עצמו" (ע"א 7193/08 **מנחם עדני נ' מרדכי דוד**, בפס' 9 לפסק-דינו של השופט פוגלמן (18.7.2010)). אם כן, נראה כי בפירוט הסכם 2009 והמסוימות שבו יש בכדי להאיר ולהבליט את היעדרה של מסוימות כזו בהסכם 2006 וממילא על היעדר גמירות-דעת של הצדדים. משכך, ממילא, לא ניתן לראות בהסכם 2006 הסכם מחייב שהצריך מהנתבעים להגיש הודעת ביטול על מנת להשתחרר ממנו.

35. אולם, גם אם נכון הייתי להניח שהסכם 2006 או הסכם 2009 הם הסכמים ברי תוקף, הרי שהוא אינו מהווה הסכמה מפורשת לבנייה הנוכחית של הנתבעים על גבי הגגות. כפי שצינתי לעיל, שני ההסכמים עסקו בסיטואציה עתידית "עת יירשם הבית כבית משותף", ולא במצב הנוכחי. וזאת, יש גם להבהיר, כי ההסכמים הנ"ל עסקו בעיקרם בניסיון הצדדים לרשום את הבית המשותף. הדבר עולה בבירור הן מלשון הסכם 2006 העוסק בעיקרו בלוח התשלומים לעו"ד רוטברט וחוב הקבלן עבור מס רכישה וזאת לצורך רישום הבית המשותף והן ממכתבים ששלח עו"ד רוטברט בתקופה זו לרשויות המס (צורף כנספחים 3 ו-5 לתצהיר סלח). רוצה לומר כי אין מדובר בהסכם ייעודי לחלוקת הזכויות אלא הסכמה עקרונית נלווית למועד מאוחר יותר, בשעה שבו יירשם הבית כבית משותף, ומכל מקום הוא אינו יכול להוות הסכמה מפורשת לבנייה על הגגות או להענקת זכויות בנייה. קביעה זו גם מתיישבת עם המצב בשטח, שכן נכון להיום גם הנתבעים אינם מאפשרים (באופן אקטיבי או פאסיבי) לתובעים לעשות שימוש ייחודי בשטח הגגות על אף האמור בהסכם, ומכאן כי התנאים השלובים בחוזה לא השתכללו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/412/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. העולה מן האמור שהנתבעים הציבו את התובעים עם מצב מוגמר לפיו קיימת בנייה בלתי חוקית בשטח הגגות ומנסים "להכשיר" את הסכמתם בדרך של הסכמים שנחתמו בשעתו בעניין רישום הבית המשותף. במצב דברים זה הנתבעים לא יכולים לטעון להסתמכות על הסכמת הנתבעים, שכלל שניתנה הרי שהיא ניתנה לאחר שהושלמה הבנייה וזאת כחלק מהסכמות עתידיות לאחר רישום הבית המשותף. בנסיבות אלה וכפי שבואר לעיל, גם אם מדובר היה בחוזים ברי תוקף, הם אינם יכולים להוות הסכמה לבנייה האמורה.
37. מכיוון שנמצא שהסכמים 2006 ו-2009 לא נכנסו עוד לתוקף, מאחר שהבית טרם נרשם בכית משותף, יש לבחון האם ניתנה הסכמה בנפרד לבניה, שלא במסגרת ההסכמים הנ"ל.
38. אומר בקצרה, שהנתבעים לא הוכיחו כי ניתנה להם רשות בעל פה או בהתנהגות מהתובעים לבניה האמורה. מכל מקום, גם אם ניתנה רשות כאמור, בהינתן שהתובעים לא קיבלו מאומה עבודה, שכן אין מחלוקת שהתובעים לא עושים שימוש ייחודי בשטח הגגות, הרשות שניתנה היא רשות גרידא המסווגת כרשות חנם או כרשות שמכללא מכוח שתיקה לאורך השנים (שכאמור, לא הוכחה על ידי הנתבעים), ועל כן זו, ככלל, ניתנת לביטול (ע"א 96/50 צינקי נ' כיאט, פ"ד ה(1) 474 (1951); ע"א 50/77 מזרחי נ' אפללו, פ"ד ל"א(3) 433 (1977); וראו פסק דיני בתיק (מפקח על רישום מקרקעין חולון) 488/20 פורת נ' מנור (17.7.2022)).
39. עוד טענו הנתבעים בסיכומיהם להחלת הלכת רוקר נ' סלומון (רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199 (1999)) שקבעה, בין היתר, כי הזכות העומדת לבעל דירה לדרוש סילוק יד מבנייה בלתי חוקית בבית המשותף אינה מוחלטת וייתכנו מקרים שזכות זו תיסוג מפני עקרון תום הלב. ואולם, בנסיבות האמורות בהן לא הוכחה כי ניתנה הסכמה לבנייה ואף הוכח שהתובעים פעלו לאורך שנים לסילוק ידם של הנתבעים מהגגות, אם בהיבט האכיפה התכנוני ואם בזה הקנייני, ומשעה שגם נכון להיום מדובר בבנייה ללא היתר כדין, לא ניתן להחיל את חובת תום הלב על התובעים ומטעם זה לדחות את תביעתם. נהפוך הוא (וראו: תיק (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת) 245/2019 גרין נ' שטרנבוך בפסקאות 41-45 והאסמכתאות שם (4.3.2021)).
40. לסיכום: העולה מן האמור שבהעדר היתר או ראיה להיתכנות להיתר והסכמה של בעלי הדירות ברוב הדרוש, סלח אינם רשאים לבנות בשטח הגגות, גם בחלק שאמור להיות מוצמד לדירתם. משכך, אני מורה לסלח להסיר תוך 60 יום ממתן פסק הדין את כל הבניה המצויה כיום בשטח הגגות.
41. נוכח האמור ומכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה על רישום הערה כלהלן: "ניתן פסק דין ביום 18.9.2023 המורה על הריסה בשטח הגגות הקרובים לדירת סלח או של מי מחליפיהם"

התביעה לסילוק השלשלאות מכלובי הגז



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/412/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. בעניין זה התובעים לא הצליחו להראות שהנתבעים אחראים להצבת השלשלאות למניעת הגישה לכלובי הבלונים. הנתבעים טענו בתוקף כי מדובר בפעולה של חברת הגז (סעיף 43 לתצהיר סלח) והתובעים לא הפריכו טענה זו. מכל מקום, נכון להיום גם לתובעים יש גישה לבלונים (ראו עדותו של התובע 2 בעמ' 8 שורה 38) ועל כן דומה שהסעד התייטר. למען הסר ספק, על הנתבעים לאפשר גישה לתובעים לבלוני הגז בכל עת וללא תנאי.

פסיקת הוצאות

43. הכלל בפסיקת הוצאות הוא כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כך "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי דין". יתר על כן, התקנות במתכונתן הנוכחית אף מחייבות את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות (תקנה 152 לתקנות).

44. לאור התוצאה שהגעתי אליה – לפיה דין התביעה נגד סלח להתקבל, בשים לב למשך ההליך ובמשאבים שנאלצו התובעים לשאת; ומנגד, נוכח דחיית רכיב התביעה בנושא בלוני הגז, אני קובע כי הוא יישא בהוצאות התובע בסך 8,000 ש"ח. מאחר שהתביעה נגד שמעוני נמחקה, על אף שהמלצתי לתובעים לשקול את הנושא לאור מכירת דירת שמעוני, הרי שהתובעים יישאו בהוצאות שמעוני שנאלצו להגן על עצמם גם לאחר שמכרו את הדירה. מנגד, מאחר שהתביעה נדחתה שלא לגופה וששמעוני לא טרחו להציג את הסכם המכר עם הרוכשים (שייתכן כי היה נכון לכלול בו הוראה לעניין הריסת התוספות), התובע יישא בהוצאות מופחתות לטובת שמעוני בסך 3,000 ש"ח. סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ד (18 ספטמבר 2023) בהעדר.



אורי שלומי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון